

1505853-62.2021.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Disse que o local do ponto de tráfico é um dos mais movimentados da cidade e que o local onde os entorpecentes estavam sendo guardados, na Avenida Suécia, não tem ligação com Suele.

Em juízo, o policial civil Renan Ferreira Munhoz disse que houve diversas denúncias a respeito do tráfico de drogas no bairro Santa Terezinha, na Rua Honorina Franco da Rocha e na Avenida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505853-62.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505853-62.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN LUIS VALIM e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Jhonatan Luis Valim, Victor Henrique dos Santos Leal, menor de 21 anos de idade, e Suele Francisco de Paula foram denunciados e estão sendo processados, porque no dia 04 de novembro de 2021, nesta cidade e Comarca, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes, envolvendo os adolescentes Leonardo Ribeiro Aviles, Yuri Gomes Chagas e Leonardo Thalisson Teodoro de Godoi.

Consta também que, no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 07h30min, na Rua Honorina Franco da Rocha, altura do nº 170, bairro Santa Terezinha, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de estabelecimentos de ensino, de locais de trabalho coletivo e de recintos onde se realizam diversões de qualquer natureza, Jhonatan Luis Valim e Victor Henrique dos Santos Leal, menor de 21 anos de idade, envolvendo os adolescentes Leonardo Ribeiro Aviles, Yuri Gomes Chagas e Leonardo Thalisson Teodoro de Godoi, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 48 (quarenta e oito) microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 34,02g (trinta e quatro gramas e dois centigramas), substância entorpecente que provoca dependência física e psíquica, e o faziam sem autorização

e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo acima descritas, na Avenida Suécia, nº 517, bairro Jardim Novo II, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de estabelecimentos de ensino, de locais de trabalho coletivo e de recintos onde se realizam diversões de qualquer natureza, Jhonatan Luis Valim e Victor Henrique dos Santos Leal, menor de 21 anos de idade, envolvendo os adolescentes Leonardo Ribeiro Aviles, Yuri Gomes Chagas e Leonardo Thalisson Teodoro de Godoi, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 60 (sessenta) microtubos contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 42,57g (quarenta e dois gramas e cinquenta e sete decigramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, e o faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 211/212; 276/288 e 339/348) e a denúncia foi recebida aos 09 de março de 2022 (fls. 367/368).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes e os acusados foram interrogados (fls. 551/553 e 636/637).

Em memoriais, a representante do Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação penal e condenação dos acusados Jhonatan Luis Valim e Victor Henrique dos Santos Leal como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, c.c. artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, absolvendo-se a acusada Suele Francisco de Paula, por insuficiência de provas para a condenação (fls. 640/657).

A defesa do acusado Victor Henrique dos Santos Leal requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do acusado, alegando falta de provas para a condenação. Alega que não era alvo da investigação e não existe descrição da forma como operava o suposto tráfico de drogas. Alega que nada foi apreendido em seu poder e que nunca fora alvo de investigação policial. Alega que sua presença no local não constitui fundamento para a condenação, pois se trata de local movimentado. Alega que não há elementos que justifiquem sua condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, pois nunca foi visto pelos investigadores no local e as drogas apreendidas pertenciam a terceiros. Caso não seja esse o entendimento, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como afastada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, e aplicado o redutor descrito no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo. Por fim, pugna que seja aplicado regime aberto para início de cumprimento da reprimenda e que a pena seja substituída por uma pena restritiva de direitos (fls. 662/684).

A defesa da acusada Suele Francisco de Paula requer a improcedência da ação penal, absolvendo-a a acusada das imputações, nos termos no artigo 386, IV do Código de Processo Penal (fls. 685/693).

A defesa do acusado Jhonatan Luis Valim requer a improcedência da ação penal e absolvição do acusado por não ter o Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar as imputações. Caso não seja esse o entendimento, requer a fixação da pena no seu mínimo legal e a aplicação do disposto do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com a redução em seu grau máximo, pois não há provas de que o acusado pertence a organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. Requer que seja afastada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, pois não há nos autos elementos que indiquem que os frequentadores daqueles locais protegidos por Lei eram o alvo da traficância, alegando ainda que o acusado foi preso durante a pandemia de COVID-19 e que a maioria desses locais estava fechada. Por fim, pugna pela fixação do regime prisional daquele diverso do fechado, bem como a substituição da pena privativa liberdade por aquelas restritivas de direitos (fls. 694/704).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 09); pelo laudo pericial do local (fls. 192/197 e 198/203); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 179/181 e 182/184); pelos laudos dos conteúdos dos aparelhos celulares (454/460; 463/474; 475/478;

479/488; 489/492; 493/499; 500/503; 504/513; 514/519; 520/523 e 590/593); pelo laudo do aparelho telefônico (fls. 705/714 e 715/719) e por toda a prova oral colhida em juízo.

Em juízo, o policial civil João Ronaldo Valim disse que estava acompanhado de outros dois policiais e, antes das 07h00min, Jhonatan estava vendendo entorpecentes, sendo que, após esse horário, Victor passou a vender os entorpecentes, devido à troca de turno. Disse que solicitou a presença da guarda municipal para a abordagem dos acusados e dos adolescentes que estavam no local. Após a abordagem, os entorpecentes foram encontrados no local indicado, pois visualizou um dos adolescentes escondendo as porções. Disse que após a apreensão, foram até a residência do adolescente Leonardo, localizada na Avenida Suécia e lá encontraram mais drogas, além de Jhonatan, que estava no quarto do adolescente contando dinheiro. Disse que fez monitoramento somente no dia da prisão dos réus, sendo que o policial Renan fez monitoramentos anteriores ao dia da prisão. Relata que Jhonatan e Victor escondiam os entorpecentes em uma árvore e nas tubulações de saída de água pluvial, dizendo que viu os réus entregando os entorpecentes e recebendo algo em troca. Disse que a participação de Suele se deu antes da data relatada, mas quem apurou a conduta foi o policial Renan. Negou ter investigado os acusados anteriormente, sendo que, no dia da prisão, foram encontrados um mil e duzentos reais, mas não teve acesso ao conteúdo dos aparelhos. Disse que não abordaram as pessoas que compraram os entorpecentes, pois não era o momento oportuno, já que a investigação estava em andamento e o objetivo principal era encontrar o local onde estava sendo armazenada a maior quantidade de entorpecentes. Disse que o local do ponto de tráfico é um dos mais movimentados da cidade e que o local onde os entorpecentes estavam sendo guardados, na Avenida Suécia, não tem ligação com Suele.

Em juízo, o policial civil Renan Ferreira Munhoz disse que houve diversas denúncias a respeito do tráfico de drogas no bairro Santa Terezinha, na Rua Honorina Franco da Rocha e na Avenida Suécia, pois possivelmente existia um estabelecimento onde dois irmãos armazenavam entorpecentes. Informou que foram realizados monitoramentos e percebeu intensa movimentação de indivíduos na residência deles, sendo que em uma das campanhas foi possível ver um adolescente retirando possivelmente entorpecentes próximo ao local e se dirigindo à rua Honorina Franco da Rocha. Posteriormente, voltaram ao local e nessa ocasião o policial João ficou na rua em questão, fazendo a campana e ele e o policial Leandro ficaram na Avenida Suécia. Disse que notaram que um adolescente retirou entorpecentes próximo ao local onde outro adolescente tinha sido visto em campana anterior retirando entorpecentes. Após, o adolescente se dirigiu à Rua Honorina através de uma viela, entregou o objeto a outro adolescente, chamado Iuri. Em seguida, comunicaram o policial João sobre os fatos e ele percebeu a movimentação e acionou a guarda municipal. Disse que com a permissão da proprietária entraram no imóvel, tendo sido encontrados 60 micropinos de substância análoga à cocaína, um notebook furtado e a quantia de mil e duzentos reais no quarto de Leonardo e em um banheiro que estava fechado, além do réu Jhonatan, que anteriormente estava no ponto de tráfico da Rua Honorina, e que foi encontrado na casa contando dinheiro. Em relação a Suele, foi apurado que, em data anterior, um adolescente possivelmente pegou entorpecente e saiu pela viela, dirigindo-se a Suele e entregando a ela, ocasião em que a acusada escondeu dentro da camiseta e entrou em sua residência. Relatou que já haviam cumprido mandado de busca na residência de Suele em virtude de denúncias de que ela e o filho Caio guardavam entorpecentes no local. Confirmou que eles escondiam os entorpecentes na Avenida Suécia em canos, terrenos baldios e em alguns buracos nos muros, sendo que na rua Honorina dentro de canos, em árvores e, eventualmente em montes de areia. Na data dos fatos a guarda municipal encontrou os entorpecentes nos locais em que o policial João indicou a eles. Informou que foram apreendidos aparelhos celulares. Disse que investigou Suele, mas os outros acusados não. Disse que Victor não foi citado nas denúncias que deram início à investigação e nunca o investigou anteriormente. Afirma que Jhonatan disse que estava na residência porque iria dar carona à genitora do adolescente Leonardo que residia ali. Disse que Suele não tem relação com os acusados.

Em juízo, o policial civil Leandro Aldigheri disse que participou da prisão dos acusados. Disse que utilizaram duas viaturas descaracterizadas, sendo que uma se posicionou na Rua Honorina F. da Rocha, onde se localizava o ponto de tráfico e a outra, na Avenida Suécia. Disse que iniciaram o trabalho por volta das 06h45min, pois naquele ponto o tráfico é intenso e ocorre o dia inteiro, com revezamento entre os traficantes, sendo que uma equipe assume das 07h00 às 19h00 e a outra, das 19h00 às 07h00. Disse que o investigador que estava na Rua Honorina visualizou Leonardo Godoy, Jhonatan e terceira pessoa não identificada praticando o tráfico de drogas. Momentos depois, Leonardo e o indivíduo não identificado saíram em direção à Rua Honorina e, logo em seguida, ele retornou sozinho com algo embrulhado em uma blusa, sendo identificado posteriormente como sendo um notebook, entrando novamente na residência. Relatou que nesse momento o investigador que estava na Rua Honorina, viu Yuri e Victor escondendo os entorpecentes para dar início à venda, ocasião em que solicitou que a guarda municipal realizasse a abordagem. Disse que se dirigiu à residência com o outro investigador e, com a permissão da proprietária, entraram no imóvel e, no quarto do filho da proprietária, que se trata de cômodo separado da casa, encontraram os adolescentes Leonardo Ávila, Leonardo Godoy e Jhonatan. Disse que Jhonatan e Leonardo Ávila estavam contando dinheiro e Leonardo Godoy usava o notebook. Disse que a quantia em dinheiro totalizou um mil e duzentos reais, sendo que no banheiro foram encontrados sessenta pinos de entorpecentes. Informou que foram apreendidos aparelhos celulares, mas não teve acesso ao conteúdo dos aparelhos, sendo que no dia teve contato com Jhonatan e Victor, que confessaram que estavam traficando. Não teve contato com Suele.

Em juízo, Aparecida Brevi de Oliveira Áviles disse que conhece os acusados desde crianças e afirma que Jhonatan estava em sua residência, pois pediu que a levasse ao centro da cidade, pois seu esposo estava trabalhando. Quando a polícia chegou, Jhonatan estava na porta do quarto de seu filho. Negou ter autorizado a entrada dos policiais em sua residência, alegando que eles invadiram local e a acordaram. Disse que o imóvel é dividido, uma parte para os filhos e outra para ela e seu marido. Negou ter visto entorpecentes na residência, mas disse que ele estava escondido dentro do banheiro e o policial conseguiu encontrá-lo. Negou conhecer a quem pertenciam os entorpecentes, afirmando que seu filho lhe disse que estava apenas guardando para alguém, sendo que Jhonatan não tinha envolvimento com os entorpecentes apreendidos, alegando que ele havia pedido emprego ao seu marido e deveria começar na segunda-feira.

Em juízo, André Ricardo Leal, genitor do acusado Victor, disse que seu filho trabalhava com o depoente e recebia oitenta reais por dia. Disse que Victor reside com a avó e é uma pessoa boa.

Em juízo, Mauro Barbosa de Lima, marido da acusada Suele, disse que morava em frente a um ponto de tráfico e várias vezes sua esposa recebeu pedidos para que guardasse objetos. Disse que a acusada não tem envolvimento com entorpecentes e que muitas vezes precisava procurar seu filho, que é dependente químico, porém não traficava. Disse que Suele encontrou entorpecentes pela casa em razão da dependência do filho do casal. Alegou que retornava de São Paulo e dava dinheiro ao filho para que aquele comprasse entorpecentes escondidos da mãe. Algumas vezes, ela descobriu e descartou as drogas no vaso sanitário. Disse que seu filho tinha amizade com os rapazes do ponto de tráfico. Disse que a polícia sempre esteve em sua casa à procura de entorpecentes em razão do filho, jamais em virtude de Suele.

Em juízo, Leonardo Ribeiro Áviles disse que não conhece o acusado Victor e que está custodiado na Fundação Casa por tráfico de drogas. Disse que o fato ocorreu em novembro e em sua residência também estavam Jhonatan e Leonardo Tales, além do depoente. Afirma que Jhonatan estava em sua casa para levar a genitora do depoente para pagar contas. A polícia apreendeu sessenta pinos de cocaína e dinheiro em espécie em sua residência, mas o 'notebook' encontrado não era seu. Estava guardando as drogas para desconhecido e o dinheiro também era dessa pessoa.

Em juízo, Ramiro Franco disse que conhece a acusada Suele e que ficou sabendo dos fatos pelo marido dela, que pediu para que testemunhasse em favor da acusada. Disse que desconhece que ela guardasse entorpecentes. Explicou que ela cuidava das crianças, dando comida, banho e levava à escola.

Em juízo, Jane da Silva Tristão disse que é vizinha da acusada Suele e ficou sabendo dos fatos pelo marido dela. Disse que levava seus filhos para Suele cuidar. Negou ter visto a acusada guardando entorpecentes. Disse que Suele trabalhava como babá.

Em juízo, o acusado Victor Henrique dos Santos Leal negou a prática dos crimes, dizendo que estava conversando com Yuri na rua quando foram abordados. Disse que conhece o acusado Jhonatan de vista. Disse que não sabe se os adolescentes tem envolvimento com o tráfico. Disse que conhece Suele de vista, pois conhece o filho dela. Disse que não conhecia o adolescente Leandro.

Em juízo, o acusado Jhonatan Luis Valim negou a prática dos crimes, dizendo que não estava na posse dos entorpecentes apreendidos na casa do adolescente Leonardo Ribeiro. Disse que o conhece desde pequeno e a mãe de Leonardo pediu que a levasse ao centro para pagar conta. Não sabe do envolvimento dos adolescentes com entorpecentes. Disse que conhece Suele de vista, pois conversava com o filho dela. Disse que conhecia o acusado Victor de vista.

Em juízo, a acusada Suele Francisco de Paula negou que estivesse associada aos acusados para a prática do tráfico de drogas. Disse que não conhece Jhonatan, Victor e nem os adolescentes. Disse que o tráfico de drogas ocorria na esquina de sua residência. Disse que não guardava objetos para os réus ou para os adolescentes. Disse que o policial civil Renan invadiu sua casa duas vezes, sendo que havia mandado em uma delas e na outra, não. Disse que o adolescente Jeferson era conhecido de seu filho e lhe pediu para carregar o celular dele uma e, em outra ocasião, pediu água à interroganda.

Com efeito, o depoimento prestado pelos policiais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório - Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que os acusados Jhonatan e Victor realmente se dedicavam ao tráfico de drogas em razão da quantidade e forma como os entorpecentes apreendidos estavam embalados, características típicas do comércio varejista de drogas.

A esse respeito, de se anotar que o policial civil João Ronaldo Valim disse que monitorou o local desde o início da manhã e visualizou Jhonatan efetuando a venda de drogas em companhia do adolescente Leonardo Godoy e de terceira pessoa que não foi identificada, em ponto de comercialização de drogas de grande movimento nesta cidade, sendo certo que, com o término do turno de venda, Jhonatan deu lugar ao adolescente Yuri e ao acusado Victor, que assumiram a responsabilidade pela venda do entorpecente.

É certo, ainda, que o policial civil afirmou que viu acusado Victor chegando ao ponto de venda posteriormente e também efetuando a comercialização de droga, assim como que as porções estavam escondidas em canos de saída de água e em uma árvore, locais que foram indicados a guardas civis municipais, que realizaram a abordagem e apreenderam a droga.

A alegação da defesa do acusado Victor, no sentido de que nenhuma porção foi apreendida em sua posse não conduz à absolvição, na medida em que o policial esclareceu que isso ocorreu porque o increpado chegou ao local depois que as drogas tinham sido escondidas pelo adolescente Yuri, mas, ainda assim, Victor participou da comercialização do entorpecente enquanto foi realizada a campana e até a abordagem pela Guarda Civil Municipal.

O mesmo deve ser dito em relação a Jhonatan, que foi visto pelo policial João Ronaldo realizando a venda de drogas e, após o término de sua jornada no ponto de venda de entorpecentes, dirigiu-se à residência do adolescente Leonardo Ribeiro

Áviles, onde os policiais civis encontraram drogas, um notebook, que era produto de crime anterior, e R\$ 1.200,00 em dinheiro, sendo sintomático o fato de que os policiais relataram que Jonathan estava contando o dinheiro quando a equipe ingressou na casa.

Nem se diga que não houve a concordância dos moradores para ingresso dos policiais no local, pois a anuência, no caso concreto, era desnecessária, existindo fundadas razões para que os servidores públicos o fizessem, já que investigavam os envolvidos em associação para o tráfico de drogas em movimentado ponto de comercialização de entorpecentes desta cidade e, na ocasião, havia elementos que permitiam concluir pela existência de drogas ou dinheiro proveniente da comercialização espúria no imóvel.

A esse respeito, deve-se destacar a campanha realizada pelos policiais, que notaram a entrega de entorpecentes próximo ao local onde outro adolescente tinha sido visto em campanha anterior retirando entorpecentes e a ida de Jonathan e dos adolescentes para a residência de Leonardo Aviles após o término do turno de venda do acusado Jonathan.

Também não convence a versão de Jhonatan de que estava na residência de Leonardo apenas para transportar a genitora dele ao centro da cidade para pagamento de contas, pois, ainda que realmente viesse a conduzir a genitora do adolescente ao centro da cidade, sua presença, naquele momento, no interior do imóvel, ocorria para que o grupo pudesse conferir o resultado da venda de drogas ocorrida durante a noite e início da manhã, tanto que, como já dito, Jhonatan estava contando o dinheiro quando os policiais ingressaram na residência, numerário que, evidentemente, era o produto do crime de tráfico de drogas praticado por eles. Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos policiais, na medida em que os acusados nada alegaram, muito menos provaram, que pudesse indicar atuação deliberada dos agentes públicos para falsamente imputar as condutas aos acusados. Por sua vez, a acusada Suele deve ser absolvida, inexistindo prova suficiente de que ela mantinha vínculo com os acusados ou com os adolescentes, conforme bem expôs a Douta Promotora de Justiça:

Em relação à acusada SUELE, contudo, o relato do policial civil Renan, encarregado das investigações, no sentido de que ela não possuía vinculação com VICTOR, JHONATAN e com os adolescentes apreendidos, além do fato de que não houve monitoramento constante da acusada SUELE, seja telefônico, seja presencial, são elementos que devem conduzir à insuficiência de provas para a condenação desta ré em relação ao delito de associação ao tráfico de drogas (fls. 651).

Em relação ao crime de associação ao tráfico atribuído aos acusados Jhonatan e Victor, com envolvimento dos adolescentes Leonardo Ribeiro Aviles, Yuri Gomes Chagas e Leonardo Thalisson Teodoro de Godoi, entendo que a prova é suficiente para condenação apenas do primeiro.

No que diz respeito ao acusado Victor, anoto que não há prova de que ele estava associado ao corrêu e aos adolescentes para a prática, reiterada ou não, do crime de tráfico de entorpecentes.

E isso porque os policiais civis disseram que não conheciam Victor e não o haviam investigado anteriormente, assim como não houve menção ao nome dele nas denúncias que deram início às investigações.

Desse modo, ele foi visto apenas no dia em que ocorreu sua prisão em flagrante, inexistindo outros elementos que permitam afirmar que estava associado aos demais agentes para a prática do tráfico, podendo mesmo tratar-se de traficância realizada eventualmente e sem prova segura da estabilidade.

Para tal conclusão, insta consignar que o crime descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/06 exige prova segura de que o acusado estava associado aos demais agentes com ânimo definitivo e de maneira estável para a prática dessa infração.

Segundo Vicente Greco Filho, não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que

estabeleceria a coautoria (Tóxicos, Ed. Saraiva, 13ª edição, pág. 184/185). Para Guilherme de Souza Nucci, exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da lei n. 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 5ª edição, pág. 379).

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que diante da expressão "reiteradamente ou não", contida no caput do artigo 35 da Lei 11.343/2006, há que se perquirir se para a configuração do delito de associação para o tráfico basta a convergência ocasional de vontades ou a eventual colaboração entre pessoas para a prática delituosa, ou se é necessário, tal como no crime de quadrilha ou bando previsto no Código Penal, que a reunião se dê de forma estável. 2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes. 3. O Tribunal a quo, tendo reconhecido que a reunião do paciente e os demais corréus teria sido eventual, a admitiu como apta a configurar o delito de associação para o tráfico, o que contraria a interpretação majoritária que tem sido conferida ao tipo do artigo 35 da Lei de Drogas. 4. Não havendo qualquer registro, quer na denúncia, na sentença condenatória, ou no aresto objurgado, de que a associação do paciente com os demais sete corréus teria alguma estabilidade ou caráter permanente, não há que se falar no delito de associação para o tráfico, estando-se diante de mero concurso de pessoas... (HC 208.886/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe de 1º/12/2011).

No caso dos autos, de acordo com o relato dos policiais civis, a droga foi entregue ao adolescente Yuri, que escondeu as porções nos canos de saída de água, sendo certo que a presença de Victor e a comercialização de drogas não permitem concluir que estava ajustado à organização, de modo que a mera possibilidade de que estivesse associado ao corréu Jhonatan e aos adolescentes não basta para sua condenação, motivo pelo qual Victor deve ser absolvido por insuficiência de provas. Por outro lado, em relação ao acusado Jhonatan, além de ter sido visto pelos policiais civis no movimentado ponto de venda de drogas comercializando entorpecente, após o encerramento de seu turno, foi flagrado em companhia dos adolescentes Leonardo Godoi e Leonardo Aviles, na residência deste último, sendo que, neste local, os policiais apreenderam 60 porções de cocaína, um notebook furtado e R\$ 1.200,00, numerário que estava sendo contado pelo acusado Jhonatan. Ora, o policial civil Renan esclareceu que, poucos antes de o grupo se dirigir à casa de Leonardo Aviles, o adolescente infrator Leonardo Godoy pegou substâncias, que posteriormente se constatou tratar-se de kit de drogas e entregou ao adolescente infrator Yuri, para que iniciasse seu "turno" de venda de drogas, sendo que Leonardo Godoy ainda se apoderou de um notebook que estava em frente ao ponto de venda de drogas e que foi apreendido no interior da residência onde todos foram abordados.

Nesse cenário, vê-se que a prática criminosa não se encerrou com o fim da jornada de Jhonatan no ponto de venda de drogas, o que poderia indicar a casualidade da comercialização, mas, após, ele se dirigiu à residência de Leonardo Aviles em companhia deste e do adolescente Leonardo Godoy, adolescentes comprovadamente infratores, para conferirem o total do produto do crime/ato infracional que o grupo praticou, denotando a estabilidade para a prática do crime de tráfico de drogas. Por fim, e a confirmar que o tráfico de drogas era prática habitual do grupo, vê-se que exatamente no local para onde o grupo se dirigiu ao final do turno de venda do acusado Jhonatan, além de equipamento eletrônico produto de crime anterior e expressiva quantia em dinheiro, havia ainda 60 porções de cocaína prontas para a comercialização, todos elementos que permitem atribuir que o grupo se dedicava à comercialização de drogas de maneira estável.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, entendo que as circunstâncias judiciais são favoráveis aos

acusados Jhonatan e Victor, inexistindo fundamento concreto para o recrudesimento das penas.

Nesse cenário, fixo a pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, para cada um dos acusados, para o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, para o acusado Jhonatan, em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.

Em segunda fase, está presente a atenuante da menoridade em relação ao acusado Victor, sem reflexo sobre a pena aplicada, pois já estipulada no mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Ainda em segunda fase, em relação ao acusado Jhonatan, está presente a agravante da reincidência, que é específica, em razão da condenação pela prática de tráfico de drogas nos autos n. 1503249-65.2020, conforme certidão de fls. 414.

Desse modo, por se tratar de reincidência específica, necessária a majoração à razão de 1/5, resultando em pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa para o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e a pena privativa de liberdade de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 840 dias-multa, para o crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, anotando-se que os laudos periciais de fls. 192/197 e 198/203 revelam a existência de estabelecimentos de ensino e locais de trabalho coletivo nas imediações dos locais onde ocorreram as abordagens, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas e deve ser considerada como situada nas imediações.

Aliás, a lei não exige que aquele seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Ainda em terceira fase, impositivo o reconhecimento de que os acusados envolveram adolescentes em suas práticas, sendo que Victor foi flagrado comercializando drogas juntamente com o adolescente Iuri, sendo que a droga tinha sido escondida por este último pouco antes, e Jhonatan foi flagrado em companhia dos adolescentes Leonardo

Aviles e Leonardo Godoi, na residência do primeiro inimputável, onde houve a apreensão de droga, notebook produto de furto anterior e expressiva quantia de dinheiro.

Assim, por se tratar de duas causas de aumento, e especialmente pelo grande número de adolescentes envolvidos, majoro as penas em 1/5, resultando pena privativa de liberdade de 6 anos e pagamento de 600 dias multa, para o acusado Victor.

Em relação ao acusado Jhonatan, com a majoração das penas em 1/5, resulta pena privativa de liberdade de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 720 dias-multa, para o crime previsto no artigo 33 da lei n. 11.343/06, e pena privativa de liberdade de 4 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão e pagamento de 720 dias-multa e pagamento de 1008 dias-multa, para o crime previsto no artigo 35 da lei n. 11.343/06.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em benefício do acusado Jhonatan, pois é reincidente específico.

As penas impostas ao acusado Jhonatan devem ser somadas na forma do artigo 69 do Código Penal e descontadas em regime inicial fechado, seja porque superam o patamar de oito anos, seja porque se trata de reincidente específico.

Por estes mesmos fundamentos, descabe cogitar de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos em relação ao acusado Jhonatan.

Por sua vez, entendo possível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em benefício do acusado Victor, pois é primário, foi absolvido do crime de associação para o tráfico de drogas e não era conhecido dos policiais civis, de modo que não se tem prova segura de sua dedicação a atividades criminosas.

Em razão disso, reduzo sua pena em 2/3, resultando pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão e pagamento de 200 dias-multa, para o acusado Victor.

Em razão da quantidade imposta, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto, pois esse é entendimento da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu Habeas Corpus coletivo para proibir que os juízes e desembargadores da Justiça de São Paulo apliquem regime fechado a presos enquadrados no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), estendendo, inclusive, aos condenados que já cumprem pena nessa situação, conforme a seguinte ementa:

"PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1)."

O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que o réu faz jus à aplicação do artigo 44 do Código Penal.

Substituo, portanto, a pena privativa de liberdade imposta pela prática do crime por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas pelo mesmo período da privativa de liberdade, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução, e pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a entidade pública ou privada, com destinação social.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a presente ação penal e:

(i) CONDENO Jhonatan Luís Valim à pena privativa de liberdade de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 720 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, incisos III e VI da Lei nº

11.343/06, e à pena privativa de liberdade de 4 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão e pagamento de 1.008 dias-multa, dando-o como incurso no artigo 35 c.c. artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/06, penas que serão somadas na forma do artigo 69 do Código Penal e descontadas em regime inicial fechado;

(ii) CONDENO Victor Henrique dos Santos Leal à pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 200 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, §4º, c.c. art. 40, III e VI da Lei nº 11.343/06, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma da fundamentação, e ABSOLVO Victor Henrique dos Santos Leal da imputação de prática do crime previsto no artigo 35 c.c. artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

(iii) e ABSOLVO Suelle Francisco de Paula da imputação de prática do crime previsto no artigo 35 c.c. artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O acusado Jhonatan respondeu ao processo no cárcere e é reincidente específico, demonstrando que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública, destacando-se que, poucos mais de seis meses após ter sido beneficiado com o alvará de soltura expedido nos autos n. 1503249-65.2020 (fls. 414), tornou a ser preso em flagrante pela prática do mesmo crime, o que comprova que deve aguardar a apreciação de eventual recurso no cárcere. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em benefício do acusado Victor.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado Jhonatan não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois consequência lógica da condenação imposta e porque não comprovada a origem lícita do numerário.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 08 de agosto de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA